



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000085898

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0017121-43.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ISAQUE JOSE ASSIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2017

ÁLVARO CASTELLO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

VOTO Nº 3.559

Apelação Criminal nº 0017121-43.2014.8.26.0554

Juízo de Origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Santo André

Apelante: ISAQUE JOSÉ ASSIS

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

ISAQUE JOSÉ ASSIS, qualificado nos autos, foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, concedido o *sursis*, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no artigo 78, § 2º, alíneas “a”, “b” e “c”, do mesmo *Codex* (fls. 188/192).

Inconformado, apela (fls. 222/230), arguindo, preliminarmente, a nulidade do feito: **a)** por cerceamento de defesa, eis que o MM. Juízo *a quo* indeferiu o pleito de realização de perícia psicossocial; ou **b)** devido a ausência do réu na sala de audiência, durante o depoimento da vítima. No mérito, postula absolvição, sob alegada fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requer a redução das reprimendas cominadas, bem como o abrandamento do regime prisional fixado, considerando-se, ainda, o instituto da detração penal.

Contrarrazoado o recurso, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 234/237), posicionamento também adotado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls. 246/251).

É o relatório.

Ab initio, aprecio as preliminares suscitadas, rejeitando-as.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Não há que se falar em **nulidade por cerceamento de defesa**, ante o indeferimento da elaboração de perícia psicossocial.

A propósito, cumpre salientar ser atribuição do Julgador a avaliação da necessidade e conveniência das provas pretendidas, pela defensoria ou pela acusação. Por conseguinte, o motivado indeferimento das provas não constitui cerceamento de defesa ou acusação (MIRABETE, Júlio Fabbrini, *in Processo Penal*, 13ª ed., São Paulo: Atlas, 2002, p. 545).

No caso vertente, observa-se que proferiu o MM. Magistrado *a quo* juízo valorativo acerca da dispensabilidade, para o deslinde do feito, da realização da pretendida prova técnica (fls. 138).

Outrossim, conforme bem explicitado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, “*caso houvesse a conclusão no Estudo Psicossocial de alienação parental, entende-se que não é o caso de absolvição sumária. Ademais, alienação parental não é causa de inimputabilidade, nem mesmo de excludente de ilicitude a justificar a conduta criminosa perpetrada pelo apelante. Observa-se, ainda, que o Estudo requerido não é meio para se comprovar a suposta perseguição realizada pela vítima, pois seria realizado no apelante. Por derradeiro, a vítima tem o direito de não realizá-lo*” (fls. 248).

De outra parte, a ausência do réu na sala de audiência durante o depoimento da vítima igualmente não maculou a regularidade processual.

Isso porque o artigo 217, do Código de Processo Penal admite expressamente que o Magistrado determine “*a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor*” nos casos em que “*a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento”, como in casu. Aliás, o constrangimento é notório na hipótese vertente, haja vista que a violência física partiu de uma pessoa íntima.

No mais, não se pode olvidar que, de fato, a Defensoria Pública participou da audiência e teve oportunidade de se manifestar formulando perguntas, se o caso, o que evidencia a concretização da garantia da ampla defesa.

Não bastasse isso, a defesa do apelante não demonstrou prejuízo, circunstância imprescindível para o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. ART. 217 DO CPP. AUSÊNCIA DOS RÉUS DURANTE A OUVIDA DE TESTEMUNHA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CRIME CONSUMADO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA, PACÍFICA E DESVIGIADA DA RES. DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. PENA-BASE NO PISO LEGAL. REPRIMENDA IMPOSTA ABAIXO DO MÍNIMO ESTABELECIDO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. SANÇÃO EXASPERADA EM 1/3 NA TERCEIRA FASE DO CRITÉRIO TRIFÁSICO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 2. O artigo 217 do Código de Processo Penal admite a retirada



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

do réu da sala de audiência quando qualquer declarante se sentir atemorizado, humilhado ou constrangido com a sua presença, sem que se possa falar em nulidade do ato processual. Precedentes.

3. O entendimento assente nesta Corte Superior é no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, o que não restou comprovado no caso em apreço. Precedente. (STJ, HC nº 166.152/ES, Rel. Min. RIBEIRO DANAS, j. 02/08/2016).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. OITIVA DA VÍTIMA EM PRÉDIO FORA DO FÓRUM. PRESENÇA DO ADVOGADO DO RÉU. PROCEDIMENTO DE ACORDO COM A PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 217 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA.

1. O artigo 217 da Lei Penal Adjetiva permite que o réu seja retirado da sala de audiências quando a sua presença causar humilhação, temor ou constrangimento à testemunha ou ao ofendido, prejudicando o seu depoimento.

2. O simples fato de a vítima ter sido ouvida nas dependências do Ministério Público, diante do temor de ter qualquer tipo de contato com o acusado, não significa que o advogado do réu tenha sido tolhido da prerrogativa de com ele se comunicar, até mesmo porque o acesso do defensor ao seu cliente não é permitido durante o ato processual, mas antes dele, o que foi observado na espécie.

3. A reforçar a inexistência de prejuízos ao réu na espécie, tem-se que nada impede que o causídico responsável pela sua defesa, diante do teor das declarações prestadas pela ofendida, requeira a sua nova inquirição a fim de que, após comunicar-se com o seu cliente, possa



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

esclarecer o que entender de direito. (STJ, RHC nº 57628/PE, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO j. 08/09/2015).

Arredadas as prefaciais, passo, pois, ao exame do mérito.

Depreende-se dos autos que, no dia 21 de julho de 2014, por volta das 06h30, na Rua Doze de Junho, nº 22, Jardim Aclimação, na cidade e Comarca de Santo André, o apelante, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira **Solange Gomes da Silva**, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Em primeiro lugar, analisando-se os elementos de convicção carreados ao longo de toda a *persecutio criminis*, verifica-se que, na espécie, a materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/07), Laudo de Lesão Corporal (fls. 41) e pela prova oral coligida.

A autoria também é certa.

Em ambas as oportunidades em que foi interrogado (fls. 23 e 185/186), o **apelante** negou a prática delitiva. Na fase administrativa, disse que foi casado com a ofendida por aproximadamente 12 anos, tendo um filho em comum. Em um dado momento, **Solange** passou a acusá-lo injustamente de estar abusando sexualmente de sua filha, o que provocou a separação do casal. Alegou que a vítima não permitia que o interrogando visse o filho, sendo necessário ingressar na Justiça para regularização das visitas. Na data dos fatos, dirigiu-se à casa da ex-companheira e ambos começaram a discutir, empurrando-se mutuamente.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Em Juízo, aduziu que foi até a residência da vítima e lá passou a ser ofendido verbalmente por ela. Não desferiu qualquer golpe contra **Solange**, sendo que, na realidade, ela se machucou com o portão do imóvel.

Contudo, a versão apresentada pelo recorrente é inverossímil e restou isolada nos autos.

A ofendida **Solange Gomes da Silva** (fls. 10/11 e 184) confirmou os fatos descritos na exordial. Disse que conviveu com **ISAQUE** por vários anos e descobriu que ele abusava sexualmente de sua filha, razão pela qual noticiou os fatos à polícia e pediu o deferimento de medidas protetivas. Na data do ocorrido, o réu compareceu à sua residência e desferiu um soco no seu olho, evadindo-se em seguida.

Imperioso salientar que, desde que uniforme e coerente com as demais provas colhidas ao longo da instrução criminal, a palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito das relações domésticas ou familiares, assume especial relevância, tendo em vista que, em regra, tais crimes são cometidos na clandestinidade.

Corroborando com a versão acusatória, tem-se, ainda, o **Laudo de Lesão Corporal** de fls. 41, atestando ter a vítima sofrido lesões corporais de natureza leve, consistentes em “*equimose em região infraorbital esquerda do crânio/pálpebra superior esquerda*”, provocadas por agente contundente.

Aliás, ao contrário do ventilado pela defensoria, a ofendida em momento algum afirmou ter levado um soco do réu no olho direito, mas sim disse que teve um dos olhos atingidos, de maneira que seu relato não encontra qualquer tipo de contradição ou inconsistência quando



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

confrontado com a prova técnica.

O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.

No que concerne às **reprimendas impostas**, verifica-se que foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da hipótese vertente e circunstâncias pessoais do agente, tendo sido fixadas no patamar mínimo cominado à espécie, qual seja, **03 (três) meses de detenção**. Nada há, portanto, a ser alterado.

Por outro lado, inviabilizada a conversão da reprimenda privativa de liberdade em restritiva de direitos (por não se encontrar preenchido o requisito previsto no artigo 44, inciso I, segunda parte, do Código Penal), tem-se que, presentes os requisitos do artigo 77, do mesmo *Codex*, era mesmo de rigor a aplicação do **sursis**, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das obrigações previstas no artigo 78, § 2º, do Código Penal, mantida a modalidade prisional **aberta** na eventualidade de descumprimento da benesse concedida.

Repise-se, por fim, que a aplicação do instituto da detração penal não se revela adequada neste momento processual, já que a progressão de regime (que aliás, já foi estipulado na modalidade mais branda) depende de requisitos outros que não aferíveis no processo de conhecimento, como por exemplo, bom comportamento carcerário.

Diante do exposto, rejeitadas as preliminares,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.

ÁLVARO CASTELLO

RELATOR

Assinatura Eletrônica